

关法律及司法解释，主要特征包括：

1. 营利模式上，以推销等为名，要求参加者缴费或购买以获加入资格，例如，徐某某等人设立的平台，会员需用某币兑换虚拟币并购买“充能舱”来获取收益，实质是特定方式的加入资格获取。

2. 组织形式上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定，按顺序组成层级，规定内部人员达30人以上且层级三级以上应追责，本案中虽会员账号逾万、层级六十余层，但因网络传销非实名及一人多账号情况，认定传销人员数量和层级需结合其他证据综合判断。

3. 计酬方式上，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，本案中会员通过拉人头发展下线投资获取收益，具有典型“人传人”特征。

4. 欺骗性上，因组织者、领导者及参加者的收入皆来源于新加入者的“入门费”，故传销组织得以存续的必要条件即为不断引诱、胁迫新成员加入，不断骗取财物，否则将致资金链断裂，组织难以为继。如徐某某等人对外宣称平台的虚假信息以诱骗投资人，符合“骗取财物”规定。

综上，徐某某等人行为符合组织、领导传销活动罪客观特征，应认定此罪。

二、涉案虚拟货币认定及处置

虚拟货币作为一种新型资产形式，因其法律属性的模糊性与技术特性的复杂性，涉案虚拟货币的认定及处置成为司法实践中亟待解决的问题。

（一）虚拟货币的认定标准

虚拟货币通常指非由法定货币发行机构发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，以数字化形式存在，并通过特定加密技术确保交易安全与匿名性的货币替代物。在司法实践中，对虚拟货币的认定应综合考量其发行主体、流通范围、使用目的等多个方面。

本案中，涉及的E币被认定为伪数字货币，其主要特征为缺乏实际价值支撑与合法发行主体。相较于合法虚拟货币，伪数字货币往往存在更大的法律风险与投资隐患。至于用于购买E币的某币，其作为一种在特定虚拟社区中流通

的虚拟货币，虽不受法律保护，不等同于法定货币，但某币仍具商品属性，并可于境外市场上流通，具有一定使用价值与交易价值。

（二）虚拟货币的价值评估及处置

《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中明确规定所有虚拟货币在我国不具合法货币属性，但亦未否定其商品属性与财产属性。虚拟货币的价值认定直接关系到被告人的定罪及量刑。

本案中，平台会员需以某币充值兑换平台内发行的E币，而某币作为一种基于区块链技术的数字货币，与美元保持稳定对应关系，具体而言，1某币等同于1美元。基于某币的上述市场价值，公诉机关依某币折算成美元再折算成人民币的方式来计算本案犯罪金额合法有据。涉案价值人民币2000余万元某币经公安机关扣押后，依法定程序进行拍卖处置，实际价值亦按照1某币等同于1美元进行兑换。

三、网络型传销罪“情节严重”认定

根据《意见》规定，组织、领导的参与传销活动人员累计人员达120人以上或资金累计达250万元以上可认定为“情节严重”。因网络传销证据收集难、人员非实名且有一人多账户情况，以传销资金数额认定可能更合适。本案中，据鉴定意见，涉案平台购买“充能舱”涉案金额折算成人民币均超250万元，且徐某某退出时带走及公安机关扣押的某币价值也超250万元，以传销资金数额认定为“情节严重”符合规定，会员数和

层级可在量刑时参考。总之，对网络 型组织、领导传销活动罪的准确认定和恰当处置，对维护市场经济和社会秩序至关重要。

编写人：江苏省南通经济技术开发区人民法院 蒋长永 陈鹏

不具备期货经纪业务从业资质 但收取客户手续费营利的行为性质认定

——樊某等非法经营案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2022)渝05刑终728号刑事判决书

2. 案由：非法经营罪

【基本案情】

2018年至2019年，被告人樊某出资成立了4家公司(均不具备从事经营期货业务的资格)，并与被告人高某某收购了另一无从事交易期货业务资质的公司。

被告人高某某要求宋某某等人在期货公司开设期货交易账户，并在该公司开通融航资管平台，该平台可通过下载期货交易APP与期货公司进行期货交易业务。后被告人高某某利用上述平台寻找代理商开发不特定多名客户使用上述APP炒期货的同时收取高额手续费。

被告人樊某与被告人高某某协商由高某某提供交易平台及向主账户提供保证金，由樊某开发期货交易客户，客户每完整交易一手收取1200元的手续费，其中高某某收取190元的手续费，剩下的返还给樊某。

被告人樊某实际开拓客户、经营期货业务的流程为：由员工冒充证券公司工作人员向社会不特定人员打电话，询问炒股意向后添加客户社交软件账号，组建群聊，虚构在讲师指导下炒期货赚钱等事实，诱使客户炒期货。员工指导

客户下载上述软件，并告知客户期货交易当日必须强制平仓的交易规则及每完整交易一手需收取手续费1200元的事实，客户拟进行期货交易的入金款项均进入指定的私人账户。客户下载软件填写注册信息后，入金后并经高某某所涉公司审核后即可在软件上进行期货交易。

交易过程中，被告人高某某、樊某等允许客户以比正规期货交易较低的保证金进入期货交易市场并收取高额手续费，约定客户每日的期货交易不持仓过夜并于当日强制平仓，并商议通过特定的功能（客户当日平仓的指令在期货公司的服务器上会自动修改为反向开仓，次日有客户新开仓或平仓交易指令对主账户仓位进行平仓操作）赚取更多手续费。经审计，自2019年12月至2020年5月，前述涉案公司吸收客户累计入金5000余万元，交易手续费1700万余元。通过非法经营期货交易业务，被告人樊某违法获利400万余元，被告人高某某违法获利288万余元，被告人张某违法获利30万余元等。

【案件焦点】

樊某等人的行为构成非法经营罪还是诈骗罪。

【法院裁判要旨】

重庆市巴南区人民法院经审理认为：被告人樊某、高某某、张某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。对于公诉机关指控被告人樊某等涉嫌犯诈骗罪的问题，参与期货交易的客户对于交易模式的高风险性、收益的不确定性、及正规期货交易规则应具有一定认知，客户在进行期货交易时知晓存在当日强制平仓及收取手续费等相应规则，即客户对期货交易存在实质控制权，而涉案公司在与客户进行交割、结算的过程中未隐瞒规则、修改数据、限制交易的行为，涉案公司诱导、建议客户利用平台的优势地位、建议客户交易及对冲平仓（锁仓）赚取手续费系各被告人通过非法经营牟取利益的行为，该行为不应认定构成诈骗罪。重庆市巴南区人民法院作出如下判决：

被告人樊某等犯非法经营罪，判处八年至三年不等有期徒刑，并处600万

元至20万元不等罚金；被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40万元；追缴被告人樊某、张某等人400万元至11万元不等违法所得，上缴国库。

宣判后，张某不服，提出上诉。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：张某在二审期间提供重要线索，得以侦破其他案件，有立功表现，可以从轻处罚，但不属于重大立功表现，故对其不宜适用缓刑。重庆市第五中级人民法院作出如下判决：

维持重庆市巴南区人民法院(2021)渝0113刑初8号刑事判决第一至五项、第七至十三项，即被告人樊某等犯非法经营罪，判处八年至三年不等有期徒刑，并处600万元至20万元不等罚金；追缴被告人樊某、张某等人400万元至11万元不等违法所得，上缴国库；撤销重庆市巴南区人民法院(2021)渝0113刑初8号刑事判决第六项，即被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40万元；上诉人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40万元。

【法官后语】

一、诈骗罪犯罪构成模式

诈骗罪的犯罪构成模式是主观上行为人出于故意且具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实或者隐瞒真相的欺骗行为，被害人因此而陷入错误认识，并基于错误认识而向行为人处分财物，即行为人取得财物，被害人遭到财产损失。对于后者而言，被害人由于受骗，不了解事实真相，表面上看是“自愿”交出财物，实质上是违背其本意将财物转移给他人占有。包括两个层面，首先被害人处分财物，是因行为人实施了欺骗行为，其次被害人因对行为人实施的行为及发生的事实真相有认识错误，误以为行为人实施的行为有利于其自身利益而处分财产。即被害人处分财产与行为人实施欺骗行为存在直接因果关系。本案樊某等人虽实施了冒充炒股讲师等发送虚

假盈利截图，擅自修改客户交易指令等诱导客户进行期货交易，但客户对于期货交易存在实质控制权，即是否交易、交易几手均有自愿选择的权利。客户系在明知交易规则，且

具有自觉交易自主权的基础上处分自己的财产，樊某等人上述欺骗行为并非参与期货交易的客户陷入错误认识从而处分其期货资金的根本原因。

二、诈骗罪欺骗程度的认定

从诈骗罪犯罪构成上看，似乎并无欺骗程度的要求，但“实际上，域外刑法理论与审判实践都要求欺诈行为必须达到一定程度。简言之，只有当欺骗行为足以导致受骗者陷入处分财产的错误认识，该欺骗行为才是诈骗罪中的欺骗行为，进而才可能成立诈骗罪。”^①“被害人的错误认识，本质上是与法益有关的错误认识。在被害人错误认识属于与法益有关的错误，被害人基于该错误认识而作出财产性处分行为的场合，行为人成立诈骗罪。”^②被害人的错误认识与其从事的交易类型、所应具备的注意能力及负担的注意义务紧密相关。就部分需要专业知识或专业常识的领域而言，被害人的注意义务与注意能力更高，识别欺骗的能力也应高于一般民众，行为人对此类被害人实施诈骗构成犯罪要求的欺骗程度和认定标准相对更高一些，这在期货市场交易中体现越发明显。对于期货市场交易领域涉诈骗罪的欺骗程度的认知不仅应坚持诈骗罪认定的核心要件，即欺骗行为是否足以使被害人陷入错误认识从而处分财产，还应坚持结合期货市场交易领域的特殊情况具体认定。如果相对人依据基本的常识常理或者稍加判断即知道行为人实施的行为是欺骗行为，或者对行为人表述的相关事实的真实性产生怀疑，且有能力通过一定的方式可以查知真实情况，可以识破骗局

，从而不处分自己的财产，但却不采取相应的查证措施，选择相信行为人的表述并根据行为人的表述处分财产进而造成财产的损失，该行为不应认定为 诈骗犯罪意义上的欺骗，行为人不应当认定成立诈骗罪。本案中，多数通过樊某 等人公司平台购买期货的客户对期货相关领域知识均有一定储备或认知，尤其 是对我国金融类期货开户条件、购买要求、正规期货交易规则等均应具有一定的认知。客户明知自身资金不足以进行金融类期货交易，才在樊某等人公司平 台进行期货交易，故樊某等人的行为不成立诈骗罪。

①张明楷：《外国刑法纲要》，清华大学出版社2007年版，第580页。

②马卫军：《论诈骗罪中的被害人错误认识》，载《当代法学》2016年6期。

三、诈骗罪财产损失之探析

诈骗犯罪是结果犯，行为人实施诈骗行为造成被害人损失。衡量财产损失的基本标准是财产总量的减少。另外，从商品的交换价值与使用价值的角度看，人们使用商品的目的在于满足自身需求，财产的使用价值即得到体现。若财产的使用满足人们目的追求，即使该财产减少或消失，也不应认定为财产损失。故，诈骗犯罪财产损失认定，还应兼顾考量财产使用价值是否实现，即财产处分人使用财产的主观目的是否实现，若已实现，则也可以认为阻却财产损失的成立。本案中，通过樊某等人公司平台购买期货的客户的主观目的是在自身条件不满足的情况下，借助于他人从事期货交易进而获利。樊某等人为客户提供交易机会，并与之约定交易规则，客户在明知期货交易规则的情况下，仍参与樊某等人设置交易活动，且部分时段获取了利益。故，从财产的使用价值维度看，通过樊某等人公司平台购买期货的客户财产客观总量虽然减少了，但其实现了自己设定的从事期货交易的主观目的。在此意义上，不宜认定其财产产生了损失。

编写人：重庆市巴南区人民法院 苏志辉
王勤勤

代还信用卡到期欠款后，使用POS机(销售点终端机)
以虚构交易方式套出款项归还垫资款的行为认定

—— 王某等非法经营案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省沭阳县人民法院(2023)苏1322刑初444号刑事判决书

2. 案由：非法经营罪

【基本案情】

2020年1月至2023年2月，被告人王某分别在某小区北门东侧体育彩票店、某1小区南门东侧某门市放置POS机，主要业务是以虚构交易的方式，通过向持卡人的信用卡先还款再使用POS机刷卡将所还款项套出的方式，先后替多名信用卡持卡人进行“养卡”，偶尔也利用POS机直接套现后向信用卡持卡人支付现金，按照交易金额的1%~1.5%比例收取手续费。经统计，涉案POS机非法经营数额共计人民币3亿余元，从中牟利人民币120万元，被告人王某个人非法获利人民币61.58万元。

被告人尤某、丁某、胡某均在某小区北门体育彩票店工作，被告人丁某、胡某均领取固定报酬，被告人尤某前期领取固定报酬，2022年6月左右开始参与门店利润分成。被告人李某在某1小区南门某门市工作，领取固定报酬。被告人共计提供26张银行卡通过POS机进行非法资金结算支付活动。其中，被告人尤某自2020年3月至2023年2月，提供5张银行卡进行非法资金支付结算，结算资金共计人民币4228万余元，个人非法获利20万余元；被告人丁某自2020年3月至2023年2月提供7张银行卡进行非法资金支付结算，结算资金共计人民币1.21亿余元，个人非法获利人民币13.47万元；被告人胡某自2020年9月至2022年5月提供6张银行卡进行非法资金支付结算，结算资金共计人民币5520万余元，个人非法获利人民币10万元；被告人李某自2020年7月至2022年7月共提供8张银行卡进行非法资金支付结算，该银行卡结算资金共计人民币8525万余元，个人非法获利人民币14.95万元。

在侦查过程中，公安机关从被告人王某、丁某处扣押供作案使用的POS机13台，并扣押手机8部、电脑主机3台、信用卡918张。在审理过程中，被告人王某等5名被告人退出全部违法所得。

【案件焦点】

1. 被告人王某等人的行为是否属于非法从事资金支付结算；2. 被告人王某等人的行为是否属于信用卡套现。

【法院裁判要旨】

江苏省沭阳县人民法院经审理认为：被告人王某、尤某、丁某、胡某、李某未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，非法经营数额均在2500万元以上，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人王某、尤某、丁某、胡某、李某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人王某、尤某、丁某、胡某、李某共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人尤某、丁某、胡某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；因被告人尤某后期参与门店利润分成，而非领取固定工资，在量刑时与作为员工的其他被告人有所区别。被告人王某、尤某、丁某、胡某归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人李某犯罪以后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王某、尤某、丁某、胡某、李某自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人王某、尤某、丁某、胡某、李某均主动退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人尤某、丁某、胡某、李某均系初犯，认罪悔罪态度较好，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，故依法均宣告缓刑。综上，公诉机关对被告人王某提出的量刑建议及对其他被告人建议适用缓刑的量刑适当，均予以采纳。对各辩护人提出的被告人具有的从轻、减轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项、第四条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币62万元；

二、被告人尤某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并

处罚金人民币20万元；

三、被告人丁某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币14万元；

四、被告人胡某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；

五、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币15万元；

六、被告人王某、尤某、丁某、胡某、李某分别退至本院账户的违法所得人民币61.58万元、20万元、13.47万元、10万元、14.95万元，均予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

信用卡代还款(俗称“养卡”),是指在信用卡持卡人透支信用额度后无力还款的情况下,行为人先垫资替持卡人归还信用卡欠款,后再使用POS机以虚构交易的方式将持卡人信用卡内额度刷出归还垫资款,信用卡持卡人的透支金额未发生较大变化,仅延长了当月账单还款期限,行为人从中收取一定的手续费。因社会经济大环境影响,社会上近几年涌现出一批专业从事信用卡代刷代还业务的人员,对于该类行为是否构成非法经营罪,在定罪量刑时适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》还是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》规定的定罪量刑标准,在司法实践中存在一定争议。本案在审理过程中,主要存在以下两种观点。

第一种意见认为,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定,使用POS机以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。行为人仅利用POS机为他人信用卡代还款(俗称“养卡”),并非向持卡人直接支付现金,不构成非法经营罪。

